

1500152-04.2020.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... furto. Receberam informações sobre tráfico de drogas e em deslocamento, conversaram com a Janaína a respeito de tráfico, sendo que ela negou o crime e autorizou a vistoria. Visualizou uma televisão com um risco na tela. Como já tinha conhecimento do furto, ligou para o policial Marcelo e perguntou se havia um televisor com um risco dentre os subtraídos e ele confirmou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500152-04.2020.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500152-04.2020.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2030841/2020 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 6162190 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 1011/2019 - 1º Distrito Policial de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO VAGNER DA SILVA

Prioridade Idoso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra FABIO VAGNER DA SILVA imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado (Art. 155 § 1º § 4º, I do CP).

Narra a denúncia que no dia 29 de setembro de 2019, durante a madrugada, na Rua Dom Bosco, nº 722, Antena, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.48/54 dos presentes autos, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculos, diversas ferramentas e ao menos oito aparelhos televisores, de marcas e modelos variados, avaliados em R\$ 10.200,00 (cf. auto de fls.21/22), pertencentes ao estabelecimento comercial "Casonato".

A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2020 em decisão de fls.122. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fls.160/163.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, afastamento da qualificadora, da causa de aumento, com pedidos relativos à aplicação da pena.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou

regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (inquérito policial de fl.01, portaria de fls.02/03, boletim de ocorrência de fls.04/05, termo de declarações de fls.06, 09, 13, 40, 48, termo de depoimento de fl.41 autos de exibição e apreensão de fls.43, laudos periciais de fls.23/30), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Sérgio Casonato narrou que falou que quando foi abrir seu estabelecimento, por volta das 8 horas da manhã, estava todo revirado, faltando vários equipamentos televisores. Foram vários aparelhos furtados, que pertenciam à sua loja e a clientes. Só conseguiu recuperar um aparelho televisor. Estima que tenham sido mais de 10 aparelhos subtraídos. Os fatos devem ter ocorrido de madrugada, mas não sabe precisar a hora. Supõe que eles tenham arrebatado um vidro no mezanino, mas não sabe dizer como saíram - acredita que tenham saído pela porta da frente, mas simulando que pela porta dos fundos, Houve rompimento de cadeado. Teve de ressarcir os clientes que tiveram os aparelhos furtados. O prejuízo foi de mais de R\$ 15.000,00.

O policial militar Fernando Jacinto Richard Quintas relatou que foi o responsável pela apreensão de uma televisão deste furto. Receberam informações sobre tráfico de drogas e em deslocamento, conversaram com a Janaína a respeito de tráfico, sendo que ela negou o crime e autorizou a vistoria. Visualizou uma televisão com um risco na tela. Como já tinha conhecimento do furto, ligou para o policial Marcelo e perguntou se havia um televisor com um risco dentre os subtraídos e ele confirmou que sim. A Janaína então falou que havia comprado no "compra e vendas". Falou a ela que era produto de furto e que teria de apreender o aparelho. Posteriormente, tal pessoa falou que havia comprado o aparelho de um rapaz conhecido como Batoré, por R\$ 600,00, cujo nome acredita ser "Vagner".

O policial civil Jonas Eduardo Canato alegou que o fato diz respeito a um estabelecimento comercial de conserto de televisores. Foram ao local e conversaram com a vítima. Na época, o acusado Fábio já era suspeito, por passagens a anteriores a furtos semelhantes, de televisores, em residências e lojas. Em razão de uma ocorrência onde apreendida uma televisão, conversaram com a pessoa que estava em sua posse, e ela confirmou que havia comprado do Fábio Vagner e que inclusive havia outras que ele estava comercializando, dando detalhes da quantia e negociação, e dizendo que já conhecia o Fábio como pessoa que comercializava esse tipo de bem. A testemunha Janaína Fernanda Sales falou que comprou um televisor por meio do Facebook, na página "compras e vendas", tratando com pessoa cuja identidade não se recorda. Buscou o televisor na casa do acusado Fábio, o qual já conhecia. Fez o pagamento ao próprio acusado Fábio.

Interrogado, o réu negou os fatos, limitando-se a dizer que não praticou o furto. Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto qualificado é procedente.

De início, quanto à consumação do furto, assim como para o roubo (súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se (AgRg no HC 583297 / SC): "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan

Pacionik, DJe de 26/05/2017).

Veja-se que a vítima confirmou a subtração de diversos televisores de seu estabelecimento, em prejuízo estimado de R\$ 15.000,00.

A polícia militar, em diligência realizada por conta de possível crime relacionado a entorpecentes, acabou por localizar um dos televisores subtraídos, em poder de pessoa de nome Janaína, a qual teria informado que comprou de Vagner.

Os policiais civis que realizaram a investigação confirmaram tal ponto e, derradeiramente, Janaína foi ouvida e confirmou ter comprado o televisor de dois rapazes, dentre eles o acusado.

Nota-se, assim, que as provas são fartas a indicar o réu como, de fato, autor do delito. O número de televisores de fato é relevante e leva a crer que possivelmente o fato tenha sido praticado por mais de um agente (o que também qualificaria o crime). Isto não infirma as provas de autoria contra o réu, sendo que trata-se de mera presunção ou ilação não comprovada, não podendo então ser atribuída tal qualificadora em seu desfavor.

Some-se como elemento indiciário o fato do réu ter ao menos 5 condenações por furtos praticados na mesma época dos fatos retratados nestes autos (fls. 195/199). E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o depoimento ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

O laudo de fls. 23/30 atesta o rompimento de obstáculo, devendo então ser reconhecida tal qualificadora.

Cabe, ainda, reconhecimento de que o fato foi praticado durante o repouso noturno, conforme atestado pela vítima, que chegou pela manhã no estabelecimento e notou o furto praticado durante a noite. Anoto que a circunstância reveste o fato de maior reprovabilidade pois praticado justamente no momento de descanso geral, o que facilita a prática do delito e sua consumação, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens patrimoniais - REsp 1.979.989-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022. (Tema 1144).

Todavia, tratando o presente feito de furto qualificado e após o acolhimento da insólita interpretação "topográfica" para impedir o reconhecimento da majorante pelo STJ nos casos abarcados pelo § 4º (o que repercutirá na impossibilidade de se considerar o furto qualificado como privilegiado ou mesmo insignificante, já que a interpretação topográfica deve prevalecer tanto para o § 1º como para o § 2º e para a figura de menor gravidade que é a insignificância), consolidada no REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022 (Tema 1087), a circunstância será valorada na primeira fase de aplicação da pena, como circunstância judicial negativa, e não mais como causa de aumento.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa

considerada somar-se-á à pena mínima $\frac{1}{8}$ sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($\frac{1}{6}$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $\frac{1}{6}$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de $\frac{1}{8}$ (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes

serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, deve a pena ser exasperada em 3/8, em razão i) da maior reprovabilidade do fato, cometido durante o repouso noturno (conforme fundamentação), ii) das consequências do crime (a vítima teve prejuízo estimado em R\$ 15.000,00) e iii) dos antecedentes do acusado (fls. 195/199), já que cometeu ao menos cinco crimes anteriores ao fato deste processo, mas cujo trânsito em julgado se deu durante o trâmite deste feito. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes."

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (2 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 5 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (2 anos) o montante de 2 anos e 3 meses de reclusão, equivalente a 3/8 de 6 anos e de 350 dias-multa (intervalo de pena estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime) e estabeleço a pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente (fl. 194, trânsito em julgado para a defesa em abril de 2019). O que demanda a exasperação em mais 1/6, pelo mesmo modo de cálculo, o que representa 1 ano de reclusão e 58 dias-multa. A pena vai a 5 anos e 3 meses e 199 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Sendo assim, a pena fica em 5 anos e 3 meses e 199 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime e circunstâncias judiciais desfavoráveis, quantidade de pena (superior a 04 anos - súmula 269 do STJ) e reincidência, deve ser o fechado.

Diante de tais parâmetros, especialmente quantidade e reincidência, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO FABIO VAGNER DA SILVA, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 199 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo solto e não vislumbro razões contemporâneas para decretar sua prisão.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à advogada que atuou pelo convênio. Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 17 de novembro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)